



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
מר ארז שטיינברג**

תובעת:

צוויק דינה
באמצעות ב"כ: עו"ד אוהד צוויק
רח' אייזיק רמבה 14, ת.ד. 24, נתניה

נגד

1. סולימן יצחק
 2. סולימן מרים
 3. בדש רפאל כלאפו
 4. בדש רוזי
 5. סוויד שלומיק
 6. סוויד אתי
- רח' רד"ק 7, נתניה

פסק דין

עניינה של התביעה, טענת התובעת להסגת גבול והשתלטות נמשכת מצד הנתבעים על הרכוש המשותף. במסגרת התביעה מבוקש ליתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם מהרכוש המשותף, להרוס בנייה בלתי חוקית ולהשיב את המצב לקדמותו.

רקע ותמצית טענות הצדדים

1. מדובר בבית משותף ברחוב רד"ק 9, נתניה, הידוע כגוש 8238 חלקה 331 (להלן: "**הבית**"). הבית מורכב ממבנה אחד בן שלוש קומות, וכולל חמש כניסות, בכל קומה שתי דירות. על הבית חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום עם מתן צו רישום הבית המשותף ביום 27.12.1972.
2. התובעת, דינה צוויק (להלן: "**התובעת**"), היא הבעלים של מחצית מהזכויות בתת חלקה מס' 12, הנמצאת בכניסה הראשונה בקומה השנייה בבית. הנתבעים 1 ו-2 (להלן: "**סולימן**"), הם בעלים של דירה הידועה כתת חלקה מס' 1 הנמצאת בקומה הראשונה ובכניסה הראשונה של הבית. הנתבעים 3 ו-4 (להלן: "**בדש**"), הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה מס' 2, בקומה הראשונה ובכניסה הראשונה של הבית. הנתבעים 5 ו-6 (להלן: "**סוויד**"), הם בעלים של דירה הידועה כתת חלקה מס' 22, הנמצאת בכניסה הראשונה ובקומה השלישית באותו בית.
3. לטענת התובעת, סולימן השתלטו על השטח המשותף שבחזית הבית, בנו גדר שמונעת מעבר לחלק האחורי של השטח המשותף, יצרו כניסה נפרדת וייחודית לדירתם באמצעות פתיחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חומה קיימת וניכסו לעצמם שטח זה באמצעות הגבהתה של גדר קיימת. סולימן גם ריצפו את השטח המשותף, הציבו עליו מחסן והקימו פרגולה על גבי חלק מהשטח.

4. בדש השתלטו על השטח המשותף העורפי של הבית, גדרו אותו בגדר גבוהה, יצרו כניסה נפרדת וייחודית לדירתם באמצעות פתיחת פתח בחומה קיימת והצבת שער כניסה לדירתם, הקימו פרגולה ועיגנו אותה לקיר דירתה של התובעת, ללא הסכמתה.

5. סוויד השתלטו על הגג המשותף מעל דירת התובעת, הקימו מחסן על הגג, הציבו עליו מיטלטלין ופתחו פתח יציאה מדירתם לגג, ללא היתר וללא הסכמת התובעת. כמו כן, נטען שהשימוש שסוויד עושים בגג גורם להרס האיטום והבידוד מפני גשם, מה שגורם לנזקי רטיבות ולהתפוררות גג דירתה של התובעת.

6. במסגרת התביעה עתרה התובעת לסעדים הבאים: צו המורה לסולימן ולבדש לסלק ידם מהחצר המשותפת, להרוס את הבנייה הבלתי חוקית ברכוש המשותף, ולהשיב את המצב לקדמותו; צו המורה לבדש להסיר את הפרגולה המחוברת לקיר דירת התובעת; צו המורה לסוויד לסלק את ידם מגג דירת התובעת, להרוס את הבנייה הבלתי חוקית שביצעו בגג לרבות את המחסן, ולהשיב את מצב הגג לקדמותו לרבות סגירת פתח היציאה מהגג לדירתם. כמו כן, התבקש צו המורה לסוויד לתקן את האיטום בגג ולחדש את שכבת הבידוד.

7. מנגד, סולימן טענו בכתב ההגנה מטעמים, כי עסקינן בתביעה קנטרנית שהוגשה בחוסר ניקיון כפיים, שכן התובעת עצמה ביצעה תוספת בנייה ללא היתר ופגעה ברכוש המשותף, אך לא גילתה זאת בכתב התביעה. התביעה אף הוגשה בשיהוי, שכן דיירי הבית חילקו ביניהם לפני שנים רבות את השימוש בחצר הרכוש המשותף, בהסכמות שבעל פה ובהתנהגות, והתובעת אינה יכולה לשנות מהסכמה זו. בפרט, הסכימו כל הדיירים בבית שהחצר המשותפת הצמודה לדירת סולימן תהיה בשימוש ייחודי שלהם. אשר לגדר נטען שכל הדיירים הסכימו להגבהת הגדר, ושאין בכך משום הפרעה למי מהם וכלל הדיירים אף נהנים מהשבחת הבית בשל כך. סולימן הוסיפו וטענו כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לאכוף צווי הריסה שניתנו על ידי הוועדה המקומית בגין בנייה ללא היתר.

8. בדש טענו בכתב ההגנה מטעמים שהם אינם עושים שימוש ייחודי בחצר המשותפת הסמוכה לדירתם אלא שימוש רגיל וסביר. הגדרות שהוקמו מסביב לחצר הוקמו על ידי חברת עמידר ולא על ידם. גדרות נוספות הממוקמות בחלק הקדמי של הבית ובצדו המזרחי, הוקמו בהסכמת כל בעלי הדירות ללא התנגדות מצד התובעת. כל תוספת בניה שנבנתה על ידם נבנתה על פי היתר בנייה כדין. בדש בנו כניסה לשטח חצר הסמוך לדירתם שהיה "שטח מת" לצורך ניקויו ואחזקתו ואין לבדש התנגדות שהתובעת תיכנס לשטח זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. אשר לפרגולה נטען שהיא לא מחוברת לקירות דירתה של התובעת, ומבירור שנערך היא אינה טעונה היתר בנייה כדין. נוסף לכך נטען, שהתובעת עצמה היא זו שבנתה את מרפסת דירתה בחריגה מהיתר הבנייה, וכי לאורך השנים הערימה קשיים על תשלום חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

10. סוויד טענו בכתב ההגנה כי רכשו כדין את זכויות הבנייה שניתנו לניצול על גג דירתה של התובעת מחברת עמידר. סוויד הודו כי לא שילמו לתובעת בגין בניית הגג וניצול זכויות הבנייה אך זאת בשל סכסוך השכנים בבית. סוויד הוסיפו וטענו, כי התובעת עשתה דין לעצמה וקיצצה את מוטות הברזל ("קוצים") הנמצאים בגג דירתה ובכך מנעה מהם לבצע בנייה על הגג. נוסף לכך נטען כי בוצע איטום בגג וכי טענות התובעת בהקשר זה אינן ברורות. סוויד טענו טענות דומות לטענות סולימן בעניין ניקיון כפיה של התובעת, ההסכמות שהיו בין השכנים לחלוקת השטחים המשותפים והעדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לאכוף צווי הריסה שניתנו על ידי הוועדה המקומית בגין בנייה ללא היתר.

11. בין הצדדים נעשה ניסיון להגיע לפשרה אשר לא צלח, לפיכך נקבע התיק לשמיעת ראיות. ביום 9.2.2021 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית מטעמה. ביום 10.3.2021 הגישו סולימן תצהיר עדות ראשית בכתב. חרף החלטת כב' המפקחת א' שחל (כתוארה אז) על הגשת תצהירי עדות ראשית בכתב; בדש וסוויד בחרו שלא להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם. ביום 20.6.2021 נערכה ישיבה לשמיעת ראיות בתיק במסגרתה נחקר מר סולימן יצחק על ידי ב"כ התובעת בחקירה נגדית קצרה. לאחר ישיבה זו הגישו הצדדים את סיכומיהם.

12. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע וכעת, נותר אפוא להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית: סילוק יד מהרכוש המשותף

13. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כך:

בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס': 7/190/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. (הדגשה אינה במקור – א.ש.).

14. סעיף 12 לתקנון המצוי קובע כי:

החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

15. מצירופם של הוראות דין אלו עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת מבלי שהסכימו לכך כל הדיירים (למעט חריגים שנקבעו בחוק המקרקעין שאינם רלוונטיים לענייננו).

16. סעיף 2 לתקנון הבית המשותף קובע בענייננו כי -

"שינויים ו/או תוספות לדירה לא ישנו את החלקים ברכוש המשותף הצמודים לאותה דירה".

17. מלבד הוראה זו התקנון לא מתייחס לשימוש ברכוש המשותף, ובעניין זה חלות הוראות התקנון המצוי והדין הכללי, כפי שתיארתי בקצרה לעיל.

18. כמו כן, גם תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, מבלי שבוצעה הצמדה במרשם המקרקעין, מחייבת הסכמה פה אחד של בעלי הדירות, שכן, במהותה, דומה תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, מאחר שבשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף. בית המשפט העליון התייחס לכך בע"א 2525/92 **ראוכברגר נגד עיריית רמת גן**, פ"ד מז(5) (850):

"משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף שנעשית על-ידי בנייה בו ועל-ידי צירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על-ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם'..." (ר' עוד ברע"א 698/85 **בן צור ואח' נגד נעים ששון**, פ"ד מא(3) 144).

19. מן המקובץ עולה כי שימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף השולל אפשרות של בעל דירה להשתמש שימוש סביר באותו חלק, כמוהו כהצמדת הרכוש המשותף לדירה לעניין זה, ולכן מצריך הסכמת כל בעלי הדירות.

20. בעניין אופיה של ההסכמה הנדרשת, נקבע לא אחת כי הסכמת בעלי הדירות אינה חייבת להינתן במסגרת הסכם בכתב, ואף הסכמה בעל פה תיחשב כהסכמה (ר' ע"א 815/81 **כליפא נגד שאול**,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס': 7/190/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פ"ד לו(3), 78. כמו כן, נפסק כי הסכמה זו עשויה לחייב בעלי דירות אחרים, ובלבד שידעו על קיומה (ר' בע"א 1020/03 בובליל נגד שטיינר, נבו 25.2.2004).

21. בכל הנוגע להסכמה שעניינה רשות לשימוש ייחודי במקרקעין, ניתן ללמוד עליה גם מכללא, וכן מהתנהלות הצדדים במשך השנים (במובחן מהקניית זכות קניינית במקרקעין שחייבת להיות מפורשת). בע"א 32/77 טובליצקי נגד בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, נקבע כך:

"לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי מקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא".

22. בכל הנוגע למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של הבית המשותף, בהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, נפסק שיש להקפיד הקפדה יתירה על שמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה שממנה לא ניתן יהיה לחזור. ר' בעניין קונצ'יצקי לעיל:

"בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירות זכויות על ידי קביעות עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש שנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון...לא שוכנענו כי במקרה דנן מתקיימות הנסיבות שניתן ללמוד מהן על רשות בלתי הדירה. על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ולהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות".

23. מהו תוקפו של רישיון במקרקעין? הכלל הוא שמדובר ברישיון "הדיר", בר חזרה, וככלל נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. בפסיקה נקבע כי אמנם הזכות לחזור מהסכם חלוקת השימוש כפופה לעקרון תום הלב ולאיסור על שימוש לרעה בזכות הקניין, אולם רק במקרים מיוחדים שבהם לא הוכח שינוי נסיבות המצדיק חזרה מההסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על ציפיותם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הלגיטימית כי נותן הרישיון לא יחזור בו ועל הסתמכותם על קיומה [ר' ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן (נבו, 3.4.2006) פסקה 27 (להלן: "עניין קונצ'יצקי")].

24. מן המקובץ לעיל עולה, כי ניתן אמנם ללמוד על הרשאה לשימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף בבית המשותף גם מכללא, ובכלל זה מהמצב ששרר בבית המשותף משך שנים. עם זאת, גם אם המסקנה היא שרשות כזו הוענקה, אין לפרשה כהסכמה בלתי הדירה, ורשאים בעלי הדירות לחזור בהם מהרשאתם, למעט במקרים מיוחדים בהם לא השתנו הנסיבות; מקבל הרשות הסתמך על ההרשאה שניתנה לו; ויגרם לו נזק רב בביטול הרישיון.

25. נקודה נוספת נוגעת לנטלי ההוכחה. כאמור, ראוי לתת משקל לנוהג הקיים והמקובל בבית המשותף, גם אם נוהג זה לא מצא ביטוי רישומי מתאים במסמכי הבית המשותף. אולם, כאשר הנוהג הנטען שונה מהמצב הרישומי בפנקסי המקרקעין, כגון במקרה שבו נטען להסכמה של בעלי הדירות שאחד מבעלי הדירות תינתן זכות שימוש ייחודית ברכוש המשותף, נטל ההוכחה הוא על הטוענים למצב שונה מהמצב הרישומי.

מן הכלל אל הפרט

26. מעיון במסמכי רישום הבית המשותף: צו רישום הבית המשותף, התקנון המוסכם ותשריט הבית המשותף, עולה בבירור כי הרכוש המשותף של הבית לא הוצמד למי מדירות הבית. הצדדים אינם חלוקים על כך, ולפיכך אין מקום להרחיב בעניין זה.

27. מכאן, שהשאלה העיקרית שבה יש לדון בהליך דנן, היא האם הוכח כי ניתנה הרשאה לשימוש ייחודי או האם התגבש הסכם חלוקה "היסטורי" בין כל בעלי הדירות לחלוקת הרכוש המשותף באופן שלכל אחד מהנתבעים תהיה זכות שימוש ייחודית בחלק ממנו (זאת, במובחן ממתן זכות קניינית שיכולה להיעשות רק בדרך של הצמדה על פי סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין).

28. להלן אבחן שאלה זו, בזיקה לשימוש ברכוש המשותף המיוחס לכל אחד מהנתבעים על פי חומר הראיות שהוצג בתיק. בהקשר זה אעיר כי התקשיתי לדלות את העובדות מחומר הראיות הדל שהוצג בהליך זה ומהעדויות היחידה שנשמעה (באורן של כחצי עמוד פרוטוקול), הנתבעים אף לא היו מיוצגים עניין שהקשה אף הוא במיקוד המחלוקות ובבירור העובדות לאשורן. בנסיבות אלו, לא נותר לי אלא לפסוק על סמך החומר המונח לפניי.

האם הוכח כי בידי סולימן הסכמה לשימוש ייחודי בחצר הצמודה לדירתם?

29. כאמור, החצר רשומה כרכוש משותף. כעולה מחומר הראיות (נספח ו' לתצהיר צוויק, סע' 10 לתצהיר סולימן) אין מחלוקת שסולימן התקינו גדר פלסטיק מעל לחומת האבן הנמוכה שבחזית דירתם בשטח המשותף של הבית, יצרו כניסה ייחודית לדירתם וכי חצר זו נחזית להיות חצר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פרטית של סולימן המשמשת אותם ובני משפחתם באופן קבוע. שטח זה הוא מעין "הצמדה בפועל" כשלסולימן חזקה ייחודית בו.

30. סולימן טענו להגנתם כי קיימת הסכמה ארוכת שנים של כל בעלי הזכויות בבית לחלוקה זו ולשימושם הייחודי בחצר. ברם, טענה זו נטענה בעלמא ולא הובאו ראיות מספקות ומשכנעות לתמוך בה. סולימן לא הביאו לעדות את יתר בעלי הדירות בבית, לא חקרו בחקירה נגדית את התובעת - שהכחישה קיומה של הסכמה כזו (ר' סעיף 10 לתצהיר התובעת) ולא הביאו עדים רלוונטיים אחרים שייתכן והיה בעדותם לשפוך אור על החלוקה הנטענת המוסכמת, אימתי נעשתה ופרטיה. מובן שגם אין באמתחתם של סולימן כל מסמך המעיד על הסכמה פוזיטיבית כאמור.

31. על פי הפסיקה, על הטוען לזכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף מוטל הנטל להוכיח הסכמה שכזו (ר' תא (ת"א) 34217-12-18 **מיכל אבידן נ' שרון דנציג**, נבו 15.8.2022 בפסקה 26 לפסק הדין) ולפיכך נטל הבאת הראיות להוכחת טענה זו, חל על סולימן. כאמור, סולימן לא הביאו ראיות בעלות משקל להוכחת הסכמתם של כל בעלי הדירות לכך שתישלל מהם, לחלוטין, זכות השימוש בחצר המשותפת. לפיכך, לא מצאתי לקבל את גרסת סולימן כי הייתה חלוקה היסטורית וכי ניתנה הסכמה ברורה, מפורשת וחד משמעית על ידי כל בעלי הדירות. בהקשר זה, אין די באזכור שמותיהם של אנשים שונים שנתנו לכאורה את הסכמתם הנטענת לחלוקה כאמור - כפי שהעיד סולימן בחקירתו הנגדית, מבלי שאלו הובאו כלל לעדות, כדי להוכיח טענה בדבר הסכם חלוקה היסטורי (שורות 14-22 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 20.6.2021).

32. יש לציין כי הפסיקה מכירה בהסכמי חלוקה בין בעלי דירות בדבר שימוש ברכוש המשותף מקום שבו ניתנות תמורות הדדיות, דהיינו, כל בעל דירה מוותר על זכותו לעשות שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף אך מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו, דהיינו **שכל** בעלי דירות הבית המשותף עושים שימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף, כל אחד בחלקו (ראו ע"א (ת"א) 1295/03 **נוי נ' קורנפלד** (נבו, 10.7.2006)).

33. במקרה דנן, לא זו בלבד שהתובעת הכחישה בתצהירה את הטענה שנתנה את הסכמתה לחלוקה הנטענת ועדות זו לא נסתרה משלא נחקרה התובעת בחקירה נגדית, אלא שהתובעת העידה בתצהירה כי **לא קיבלה תמורה בדמות זכות שימוש ייחודית בחלק מהרכוש המשותף**. במצב דברים בו התובעת אינה עושה שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף והיא היחידה שלא "הרוויחה" דבר מההסכמות הנטענות בין בעלי הזכויות, נשללת מיניה וביה האפשרות שמדובר בחלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף.

34. נוסף לכך, גם אם אניח לטובת סולימן כי התובעת שתקה במשך שנים ושתיקה זו מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שנעשה על ידם בחצר הבית, הרי, שלכל היותר, ניתן לראות בכך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרשאה במקרקעין ללא תמורה, וזו ניתנת לביטול. כמפורט לעיל, רק במקרים מיוחדים, בהם יש להגן על אינטרס ההסתמכות ניתן יהיה לקבוע כי הרישיון שניתן לבעל דירה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף הוא בלתי הדיר. במקרה דנן, בכל הנוגע לשטח החצר לא הוכח כי סולימן הוציאו סכומים מהותיים בשטח זה ולא הוכח כי קיים אינטרס לגיטימי של סולימן עליו יש להגן. בנסיבות שבהן אין כל הסתמכות מצדם של סולימן, אין כל מניעה שהתובעת תודיע על התנגדותה להמשך השימוש הייחודי בשטח המשותף, גם אם לא מחתה בידם בעניין זה בעבר.

35. לפיכך, בהעדר הסכמת התובעת לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, ולאור ההלכה הקובעת כי שימוש ייחודי ברכוש המשותף דורש את הסכמת כל בעלי הדירות, אין אלא לקבוע כי סולימן מנוע מלעשות שימוש ייחודי בשטח זה. אשר על כן, אני מורה לסולימן לסלק את ידם מהחצר הקדמית, להסיר את גדר הפלסטיק, להשיב את החומה שעל גביה נבנתה גדר הפלסטיק לקדמותה ולאפשר גישה לחצר הקדמית לכלל דיירי הבית.

36. אוסיף כי לא מצאתי להורות על הריסת הריצוף, ועל צו להשבת המצב לקדמותו בנקודה זו, מאחר שעם סילוק הגדר תתאפשר גישה לחלק זה של חצר הבית והריצוף יכול להישאר בעינו מבלי שהדבר יתרום לתפיסת חזקה ייחודית של סולימן בחצר המשותפת. עם זאת, מאחר שמדובר ברכוש משותף ראשית האסיפה הכללית לקבל החלטות לעניין שטח זה, וזאת בהתאם לרוב הדרוש בחוק ועל הנציגות לתחזק שטח זה.

37. אשר להסרת מחסן בחצר הקדמית שבנייתו מיוחסת לסולימן. עיינתי בתצהיר התובעת, בתמונות שצירפה לתצהירה, ובתשריט המדידה שהובא מתוך תיק הבניין של עיריית נתניה (נספח ד' לתצהיר צוויק) ולא מצאתי ראיה לכך שאכן נבנה והוצב מחסן בשטח הרכוש המשותף, והיכן אם בכלל, ממוקם מחסן שכזה. מאחר שהתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח מהו המצב אליו יש להשיב את המצב לקדמותו הרי שלא מצאתי להיעתר לסעד זה. ממילא לא מצאתי לדון בטענה שעניינה הסתמכות על שתיקת בעלי הדירות המצדיקה את אי הריסת המחסן.

38. לעניין הפרגולה בדירת סולימן, סעיף 2 לתקנון המצוי (החל בענייננו מכוח סעיף 2 לתקנון המוסכם), קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף, לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

39. על טיבה של הפגיעה לפי סעיף 2 לתקנון המצוי עמד בית המשפט העליון כבר בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.05.66) בקבעו כי :

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. לאחר שעיינתי בתמונות שצורפו לתצהיר התובעת, אני מוצא כי התקנת פרגולה על גבי הקיר החיצוני של הבית, בשים לב לממדיה ולאופן בו הותקנה, היא פגיעה כמובנה בסעיף 2 לתקנון המצוי ומצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

41. לא נטען, וממילא לא הוכח כי סולימן קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית לבניית הפרגולה.

42. משכך, אני מורה לסולימן להסיר על חשבונם בתוך 60 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך פרק הזמן האמור, המתירה להם להותיר את הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק המקרקעין.

דירת בדש והשימוש הייחודי ברכוש המשותף

43. כעולה מחומר הראיות (סעי' 12 לתצהיר התובעת, ותמונות שצורפו כנספח ז' לתצהיר), בדש סגר את החצר העורפית בגדר שחלקה - כך עולה מהתמונות - מחופה ב"איסכורית", התקינו שער כניסה נפרד לדירתם ועושים בחצר זו שימוש ייחודי, באופן המונע שימוש מאחרים. כמו כן, כמובח מהתמונות, בדש התקינו פרגולה בחצר העורפית המעוגנת לקיר החיצוני של הבית המשותף.

44. בדש טענו טענות עובדתיות שונות בכתב ההגנה מטעמם, כך נטען, כי חלק מהגדר נבנה על ידי עמידר בשנות ה-70, כי השימוש שנעשה על ידם בחצר המשותפת העורפית הוא שימוש סביר שלא מונע שימוש אחרים, וכי הפרגולה שהותקנה בחצר העורפית היא פרגולה קטנה שאינה טעונה היתר בנייה ואף אינה מעוגנת לקירות ביתה של התובעת, אולם בדש נמנעו מלהגיש תצהירי עדות ראשית שיש בהם להוכיח את טענותיהם העובדתיות שבכתב ההגנה, ואף נמנעו מלחקור בחקירה נגדית את התובעת.

45. במאמר מוסגר אציין כי בדש אמנם צירפו לכתב הגנתם שני תצהירים הערוכים כתצהיר בג"צי הבאים, לכאורה, לתמוך בעובדות שבכתב ההגנה, אולם תצהירים שכאלו הם תצהירים פסולים, ושומה היה על בדש להגיש תצהירי עדות ראשית ולפרט בהם את כל העובדות אותן הם מבקשים להוכיח (ת"א (מחוזי ת"א) 12584-05-12 **מצדה מ.מ. בע"מ נ' פטר מגנוס**, בפסקה 17 (נבו 24.10.2013)).

46. כפי שהובהר לעיל, הואיל ואין מחלוקת כי החצר העורפית נכללת ברכוש המשותף של הבית ואינה מוצמדת לדירה כלשהי, הרי שלשם עשיית שימוש ייחודי בחצר העורפית יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, ולצורך התקנת פרגולה יש צורך בקבלת הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 2 (א) לתקנון המצוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. משהובאה לפניי גרסה עובדתית מטעם התובעת שלא נסתרה ואף נתמכת בתיעוד ויזואלי, ומשלא הוכח על ידי בדש ואף לא נעשה ניסיון להוכיח, כי קיבלו את הסכמות כל דיירי הבית לשימוש הייחודי שהם עושים ברכוש המשותף, מצאתי לנכון להורות לבדש לסלק את ידם מהחצר העורפית, להסיר את גדר האסכורית ואת שער הכניסה הנפרד המוביל לדירתם, ובתוך כך לאפשר גישה לחצר העורפית לכלל דיירי הבית.

48. כמו כן, לאחר שעיינתי בתמונות שצורפו לתצהיר התובעת, אני מוצא כי התקנת פרגולה על גבי הקיר החיצוני של הבית, בשים לב למימדיה, עולה כדי "פגיעה" כמובנה בסעיף 2 לתקנון המצוי ומצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

49. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בדש קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית לבניית הפרגולה.

50. לפיכך, אני מורה לבדש להסיר על חשבונם בתוך 60 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך פרק הזמן האמור, המתירה להם להותיר את הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק המקרקעין.

51. בהקשר זה אעיר כי התקנון המוסכם אינו קובע כי הקירות החיצוניים של הדירות יוצמדו לדירות, ולפיכך הן בגדר "רכוש משותף" בהתאם להגדרה הקבועה בסעיף 52 לחוק המקרקעין. מכאן, שאין כל רלוונטיות ונפקות לטענת התובעת כי עיגון הפרגולה נעשה לקירות החיצוניים של דירתה ללא הסכמתה, שכן יש לקבל את הסכמת בעלי הדירות במסגרת אסיפת הדיירים ולא את הסכמת התובעת בלבד.

52. אציין כי טענות בדש לקיומן של חריגות בנייה בדירת התובעת נטענו בעלמא ולא הובאה כל ראיה לתמוך בהן וממילא, אין בסמכות המפקח על רישום המקרקעין לדון בעילות תכנוניות. מובן שאין באמור כדי להביע עמדה לגופו של עניין ככל שיינקט הליך לאכיפת חריגות בניה לפני הגורמים הרלוונטיים.

דירת סוויט והשימוש שנעשה בגג הבית המשותף

53. אין חולק כי הגג הוא רכוש משותף היות שאין כל הוראה בתקנון הבית המצמידה את הגג לאחת מהדירות כאמור לעיל (ר' סעיף 4 לסיכומי סוויט "אני מודע לזה שזה לא גג פרטי שלי"). לתצהירה של התובעת צורפו תמונות המעידות על כך שסוויט הציבו מיטלטלין וציוד על הגג המשותף (נספח ח' לתצהיר התובעת, סעיף 13 לתצהיר התובעת). עוד נטען בתצהיר התובעת כי נבנה מחסן על גבי הגג וכי נפתח פתח מדירת סוויט לגג. סוויט לא הגישו תצהיר עדות ראשית מטעמם במסגרת הליך זה, ולא ביקשו לחקור את התובעת על תצהירה, כך, שלמעשה, לפניי גרסה עובדתית מטעם התביעה שעיקרה לא נסתרה. בפרט, אין לפניי כל גרסה עובדתית נגדית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מטעמים של סוויד להוכחת טענתם המרכזית, שקיימת הסכמה הדדית שהוענקה להם מצד יתר בעלי הדירות לשימוש הייחודי אותו הם עושים בגג.

54. בנסיבות אלו, אני מוצא לקבל את גרסת התובעת ולהורות לסוויד לסלק את ידם משטח הגג המשותף ולפנות את מיטלטליהם משטח הגג כמוכח מהתמונות שצורפו.

55. לא מצאתי לנכון להורות על סילוק והריסת המחסן שנבנה על הגג המשותף וזאת משלא מצאתי ראיה מספקת לכך כי אכן נבנה מחסן בשטח הגג המשותף, והיכן אם בכלל, ממוקם מחסן שכזה. לדעתי, אין די באמירה כללית בתצהיר כדי להרים את נטל ההוכחה הנטען ואין ביכולתי לתת סעד של סילוק יד והריסת מחסן ללא מדידה מקצועית ומדויקת, שממנה יהיה ניתן ללמוד בבירור היכן ממוקם המחסן, מידותיו, שטחו ונתונים רלוונטיים נוספים.

56. כך גם לא מצאתי ראיות מספקות לעניין הפתח בדירת סוויד שמבוקש לאטמו. לא נטען, וממילא, לא הוכח מהו המועד בו נפער הפתח, האם מיקומו הפיזי של הפתח שונה מהמיקום בעת בה נבנה הבית, אם בכלל. כך גם לא הוצגו לפני חוות דעת מקצועית ואף לא תמונה המעידה על פתח שנבנה שלא כחוק, כך שאין ביכולתי ליתן סעד כאמור. מאחר שהתובעת לא הרימה את הנטל להוכיח מהו המצב אליו יש להשיב את המצב לקדמותו הרי שלא מצאתי להיעתר לסעד זה.

57. טענת התובעת לנזקי מים שנגרמו לה כתוצאה מהריסת האיטום שבגג על ידי סוויד לא הוכחה לפניי כדבעי. זוהי טענה שבמומחיות שיש להוכיחה באמצעות חוות דעת מקצועית מתאימה. בענייננו, לא הוגשה כל חוות דעת שיש בה כדי להוכיח כי קיימת רטיבות בדירת התובעת וכי מקורה הוא בגג המשותף של הבית כנטען, לפיכך, טענה זו של התובעת נדחת. אין באמור לגרוע מאחריות נציגות הבית המשותף לתחזק את הגג המשותף, לרבות באמצעות איטומו כנדרש.

סיכום:

58. אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה לסולימן כדלקמן:

א. לסלק את ידם מהחצר הקדמית, להסיר את גדר הפלסטיק, להשיב את החומה שעל גביה נבנתה גדר הפלסטיק לקדמותה ולאפשר גישה לחצר הקדמית לכלל דיירי הבית.

ב. האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של סולימן.

ג. להסיר את הפרגולה על חשבונם וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרת הפרגולה במקומה.

59. לבדש אני מורה כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס': 7/190/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. לסלק את ידם מהחצר העורפית, להסיר את גדר האיסכורית ואת שער הכניסה הנפרד לדירתם, ולאפשר גישה לחצר העורפית לכלל דיירי הבית.

ב. האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של בדש.

ג. להסיר את הפרגולה על חשבונם וזאת בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית המתירה את הותרת הפרגולה במקומה.

60. לסוויד אני מורה כדלקמן -

א. לסלק את ידם משטח הגג המשותף ולפנות את מיטלטליהם משטח הגג.

ב. האמור לעיל יבוצע בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין ועל חשבונם של סויד.

61. יתר רכיבי התביעה נדחים בזאת. יש להדגיש כי אין באמור בפסק הדין משום "הכשר" לבנייה קיימת ללא היתר כחוק, או לביצוע פעולה כלשהי שלא על פי היתר בנייה כדין או למתן זכות קניינית כלשהי.

62. בעקבות התוצאה אליה הגעתי, בשים לב לכך שהתביעה התקבלה בחלקה בלבד, מצאתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בגובה אגרת ההליך בסך של 657 ש"ח ששולמה על ידה בלבד.

ניתנה בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 17 בינואר 2023, כ"ד בטבת תשפ"ג. המזכירות תודיע.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**